

1504679-95.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... na internação casa por crime análogo à tráfico de drogas. DA DEFESA. A despeito da manifestação do i. representante ministerial, a presente ação merece ser julgada improcedente. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS Ademais, inegável que não ficou comprovado que o delito tenha ocorrido em concurso de pessoas, tendo em vista que os supostos corréus não foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504679-95.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504679-95.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Aos 19/05/22, às 16h, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu EDVALDO SANTOS GOMES DA SILVA (preso no CDP de Belém II) e sua defensora, Dra. Emmy Pereira Otani, defensora pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia. Pelas partes foi dito que desistiam das demais ouvidas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A ação é procedente, uma vez que as provas produzidas durante a instrução criminal corroboraram por completo a acusação contida na inicial acusatória. Ao ser ouvida em Juízo a vítima Bianca afirmou que estava no veículo com seu marido e outro casal, perto do metro Paraíso, quando um homem armado e duas mulheres cercaram o carro e pediram que entregassem os celulares. Viu apenas parcialmente o rosto do rapaz, que estava do lado do motorista, seu esposo, pois um capuz cobria sua cabeça. Duas mulheres tinham abordado os passageiros que estavam atrás, batendo nos vidros. Por seu turno, a vítima Douglas, em seu depoimento judicial, afirmou que reconheceu o réu como autor do delito. Disse que, ao passar pelo semáforo em frente à estação Paraíso, foi abordado por um homem e duas mulheres, sendo que aquele estava com uma arma de fogo e anunciou o roubo, levando o aparelho celular do declarante, de Jardel e Bianca. Rastreando o aparelho telefônico, foi ao encalço dos roubadores, tendo encontrado o

acusado, momento em que avistou a Polícia Militar e solicitou ajuda. Viu também as moças que tinham praticado o assalto junto com ele, próximas a ele. A Polícia Militar deteve o acusado e com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O policial ouvido nesta oportunidade corroborou o depoimento das vítimas e informou que foi acionado por quatro pessoas em um veículo, que apontavam para um indivíduo, na região República, dizendo que ele havia roubado seus celulares junto com outras duas mulheres, sendo que as vítimas o haviam seguido em razão dos sinais dos celulares. Detiveram o acusado, que foi reconhecido pelas vítimas, tendo sido encontrado um simulacro de arma de fogo com ele. O acusado confessou ter praticado o delito. O réu, quando interrogado, confessou a prática do delito. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que EDVALDO SANTOS GOMES DA SILVA seja CONDENADO nos termos da denúncia, aplicando-se pena base em seu mínimo legal, dada sua primariedade, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento. Pela defesa foi alegado, em síntese: MMº. Juiz, o acusado foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Pena. Segundo narra a denúncia, o réu, agindo em concurso, teria subtraído para ele, mediante grave ameaça exercida por palavras, gestos e emprego de simulacro de arma de fogo, 03 (três) telefones celulares de vítimas distintas. Por meio de audiência remota, o acusado foi colocado ao lado de outras duas pessoas, momento em que a vítima Bianca não reconheceu o acusado, apontando para pessoa diversa do acusado. A vítima Bianca relatou que o agente na época dos fatos usava cabelos compridos e enrolados e usava capuz. Esclareceu que voltava de carro de um teatro com o vidro do carro abaixado, quando um homem apontou uma arma para seu marido, o motorista, e outras duas mulheres exigiram a entrega dos celulares de todos os presentes no carro. Entregaram os pertencentes pessoais. De onde estava sentada, a vítima esclareceu que não conseguiu ver totalmente o rosto do agente. Os bens não foram recuperados. Só um homem acabou sendo preso. Não houve reconhecimento formal por parte das vítimas. Por meio de audiência remota, o acusado foi colocado ao lado de outras duas pessoas, momento em que a vítima Douglas reconheceu o acusado. A vítima relatou que estava no semáforo com vidro aberto, momento que o acusado mais duas moças gritaram “perdeu” e levaram os celulares de todos os presentes no carro. O acusado foi preso após uma hora e meio depois do assalto. Esclareceu que pode ver bem o acusado pois estava próximo na hora do assalto. Por meio de audiência remota, a testemunha policial, Sr. Eduardo relatou que estava em patrulhamento no local quando uma vítima o abordou relatando que tinha sido assaltada e que conseguiu rastrear o celular furtado. Ao abordar o acusado não encontrou com ele nenhum celular. Em juízo, por meio de audiência virtual, o acusado Edvaldo relatou que de fato realizou o delito em concurso de pessoas com uso de simulacro de arma de fogo. Esclareceu que não recebeu nenhum celular no momento do roubo. Não possui nada contra as vítimas e os policiais. Já foi internado na internação casa por crime análogo à tráfico de drogas. DA DEFESA. A despeito da manifestação do i. representante ministerial, a presente ação merece ser julgada improcedente. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS Ademais, inegável que não ficou comprovado que o delito tenha ocorrido em concurso de pessoas, tendo em vista que os supostos corréus não foram identificados. Ora Excelência, a imputação de agir em concurso com indivíduo não identificado fere até mesmo o direito de defesa do acusado, uma vez que lhe impõe o dever de produzir prova negativa. Deve-se exigir que, no mínimo, se tenha a identificação dos sujeitos para configurar a presente qualificadora. Ademais, as pessoas devem estar conectadas psicologicamente, havendo adesão subjetiva à conduta criminosa de outrem, visando a um fim comum. Cezar Roberto Bitencourt brilhantemente elucida que A causalidade física é apenas um fragmento do complexo problema do concurso de pessoas, que exige também um liame subjetivo para completar-se. (...) Assim, inexistindo-se o nexa causal ou o liame subjetivo, qualquer dos dois, não se poderá falar em concurso de pessoas (In Tratado de Direito Penal – Parte Especial 3, 17. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012). Grifos não originais. Assim, não é possível encontrar supedâneo em nada nos autos para sustentar a versão acusatória, sendo de rigor que se afaste a qualificadora do concurso de agentes prevista pelo inciso IV, § 4º, do

art. 155 do CP. OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE ROUBO Além disso, em observância às provas constantes dos autos, também não há que se falar na ocorrência de três roubos em concurso formal, mas apenas um, eis que as subtrações foram realizadas num mesmo contexto fático. Por contexto fático entende-se por mesmo local, tempo e modo de execução. E foi assim que se realizou o crime perpetrado pelo acusado. Neste sentido: Roubo majorado pelo concurso de pessoas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitivas. 2. Depoimentos das vítimas e testemunha, que foram prestados com lógica e coerência, deve receber crédito do julgador. 3. Comprovada a causa de aumento atinente ao emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Arma apreendida por força da prisão em flagrante do réu em decorrência de outro roubo e reconhecida pelas vítimas do roubo destes autos. Arma periciada e constada a potencialidade lesiva. 4. Prova emprestada. Admissibilidade. Prova produzida em processo em que o réu é parte. Respeitados o contraditório e ampla defesa. 5. Demonstrada a prática da infração penal em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, impõe-se a aplicação da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). 6. A pluralidade de vítimas, no contexto de uma só ação, sem interrupção de tempo e de lugar, caracteriza crime único, e não concurso formal de crimes. 7. Fixação do regime inicial fechado, tendo em vista que o réu cometeu o crime quando estava foragido da Justiça. 8. Reprimenda reduzida. Pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00020373520118260189 SP 0002037-35.2011.8.26.0189, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 27/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/01/2015). Grifos não originais. Sendo assim, de rigor reconhecer, por ficção legal, que a subtração dos bens de três vítimas não ocorreu. Com isso haverá, ainda que ficticiamente, uma unidade de vítima (e de patrimônio) e uma grave ameaça; e, assim sendo, apenas um crime de roubo. ATOS INFRACIONAIS Não assiste razão à acusação no pleito de majoração da pena base em razão dos atos infracionais praticados pelo réu. Primeiro porque os atos infracionais seguem lógica diversa e não podem ser utilizados para nenhum fim penal, sob pena de ignorar a condição de pessoa em desenvolvimento dos adolescentes. Segundo, porque os atos infracionais não podem ser considerados como antecedentes penais já que ato infracional não é crime e medida socioeducativa não é pena. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA.CONDENACÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DOMÍNIMO LEGAL. CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENALPARA AUMENTO DA PENA. ATOS INFRACIONAIS QUE NÃO PODEM SERCONSIDERADOS MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A consideração de circunstâncias inerentes ao tipo penal para fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se inidônea, eis que referidas circunstâncias já foram consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário do delito. 2. É firme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para fins de majoração da pena base. 3. Ordem de habeas corpus concedida para fixar o regime aberto decumprimento de pena para ambos os delitos pelos quais foi condenadoo paciente. (STJ - HC: 249015 SP 2012/0150611-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2013). Grifos não originais. Dessa forma, requer-se a fixação da pena no mínimo legal. PENA AQUÉM DO MÍNIMO - SÚMULA 231 DO STJ. Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes, porém está presente a atenuante da idade do agente e sua confissão. No caso, mesmo a pena base sendo fixada no mínimo legal, ainda será possível a redução, a despeito da redação da súmula 231 do STJ. Nesse sentido são as lições de Rogério Greco, Conforme já o dissemos anteriormente, entendemos, contrariamente à Súmula 231 do STJ, que a existência de uma circunstância atenuante fará com que a pena-base encontrada seja, obrigatoriamente, diminuída, pouco importando se tendo ou não sido fixada em seu mínimo legal. O art. 65 não faz essa ressalva, pelo contrário, determina expressamente, por intermédio do advérbio sempre, que a pena deverá ser diminuída caso exista alguma circunstância atenuante.

(Rogério Greco. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 4ª ed.. p 634). Grifos não originais. A aplicação dessa súmula fere os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da isonomia. Sendo assim, visto que, nitidamente, o posicionamento expresso na súmula 231 do STJ afronta, ao menos, três princípios constitucionais ela deve ser afastada para permitir-se a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante citada. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA Cumpre salientar que, em caso de condenação, para reconhecer o aumento de pena no emprego de arma, é preciso a comprovação da sua potencialidade lesiva. É certo que, para a incidência do referido dispositivo, é preciso que a arma empregada seja capaz de aumentar a potencialidade lesiva da conduta. O fato da arma impor maior temor a vítima, não justifica o incremento da pena, ou seja, a arma pode até configurar a grave ameaça para enquadramento no art. 157 do CP, mas deve ter aumentado o potencial lesivo da conduta do agente para que configure a causa de aumento em comento, o que de forma nenhuma ocorreu. Assim, como a arma de fogo supostamente utilizada não foi apreendida e não existe comprovação de sua lesividade por outros meios de prova, de rigor o afastamento dessa causa de aumento. Por esse motivo, a jurisprudência é enfática ao rechaçar a possibilidade de reconhecimento da majorante do emprego de arma quando não tenha havido perícia. Nesse sentido: Se a arma não foi apreendida e se não houve a comprovação, por outros meios, de sua potencialidade lesiva, não pode incidir a causa de aumento de pena do § 2º, I, do art. 157 do Cód. Penal” (STJ - AgRg no HC 111143 / RS – 6ª T. – Rel. Nilson Naves, D.O. 02.03.2009) Diante, do exposto, requer-se o afastamento da majorante prevista no inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo 157, CP, tendo em vista a inexistência de comprovação da potencialidade lesiva da arma. DOS PEDIDOS: Pelo exposto, requer-se a ABSOLVIÇÃO do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, por falta de provas. Contudo, superado os pedidos acima, em caso de condenação, requer a Defesa: 1. O afastamento da qualificadora do concurso de agentes prevista pelo inciso IV, § 4º, do art. 155 do CP; 2. A fixação da pena-base no mínimo, não podendo os atos infracionais praticados pelo réu servirem para aumentar a pena base; 3. O agravamento aquém do mínimo, face a primariedade e atenuante da confissão e da idade, visto na época do acontecimento dos fatos o acusado tinha menos de 21 anos (art. 65, I do CP); 4. Afastamento da ocorrência de três roubos em concurso formal, para apenas um, eis que as subtrações foram realizadas num mesmo contexto fático; 5. O afastamento da majorante prevista no inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo 157, CP, tendo em vista a inexistência de comprovação da potencialidade lesiva da arma; 6. A fixação do regime inicial ABERTO, por ser o mais adequado ao caso em comento e a quantidade de pena a ser imposta (CP, art. 33; CPP, art. 387, § 2º), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP; 7. A concessão do direito de apelar em liberdade (CADH, art. 8.1), eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar (CF, art. 5, LVII, c/c CPP, art. 312). Por fim, requer os benefícios da gratuidade de justiça, por ser(em) o(s) acusado(s) atendido(s) pela Defensoria Pública Registra-se o prequestionamento de toda a matéria aqui debatida para os fins dos arts. 1030 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. EDVALDO SANTOS GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso com outras duas mulheres ainda não identificadas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida por palavras, gestos e emprego de simulacro de arma de fogo, 03 (três) telefones celulares de vítimas distintas, a saber: o aparelho Samsung S8, da vítima Jardel Franco da Silva; o aparelho Samsung S8 Plus, da vítima Bianca Augusta Pereira de Paula; e o aparelho Samsung Galaxy S20, da vítima Douglas Coimbra Cezar. O réu foi preso em flagrante. Citado, apresentou defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia. Em razões finais orais, pugnou o Ministério Público pela condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios outros postos neste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos

para a sentença. A materialidade dos delitos de roubos restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo do simulacro de arma de fogo, e ainda pela prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que o réu é mesmo um dos roubadores. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou o roubo, dizendo que havia outras duas mulheres assaltantes e agiu com simulacro de arma de fogo, não sabendo quantos celulares foram levados no assalto. Anotou que já foi custodiado por narcotráfico quando menor inimputável. A denúncia procede. A vítima Douglas reconheceu o réu, com certeza, como sendo um dos assaltantes, com perfilhamento, em juízo. Disse que foram as vítimas abordadas pelo réu e duas moças assaltantes, estando o ora acusado com arma de fogo. Aduziu que foram levados três celulares, de três vítimas diferentes, cada qual portando seu aparelho quando despojadas. Viu o réu posteriormente, perto das moças, pois um dos celulares, com localizador, indicava o local, e então chamou a polícia, que prendeu o réu com o simulacro de arma de fogo, não tendo os celulares sido recuperados. Bianca não reconheceu o réu em juízo, mas depois explicou que não conseguiu ver bem o rosto do assaltante quando do roubo. Confirmou que eram três os roubadores, e que três celulares foram levados, de três vítimas. A testemunha Eduardo soube do roubo por uma das vítimas. Eram três assaltantes, um deles armado. Um dos celulares levados indicou localização, e o réu estava nas proximidades. Não encontrou os celulares roubados com ele, mas sim simulacro de arma de fogo. Disse que as vítimas reconheceram o réu sem dúvida. Afirmou que o réu lhe confessou informalmente a autoria do roubo. A prova colhida indica a procedência da ação, nos termos já indicados. Houve confissão judicial, o réu foi reconhecido em juízo por vítima e ainda foi encontrado com simulacro de arma de fogo utilizado no momento do assalto. Os roubos se consumaram. Ocorreu plena inversão da posse dos bens roubados, sendo completada a grave ameaça e a violência, circunstâncias bastantes para a consumação dos delitos, aliás como vem entendendo as Cortes Superiores. Tais bens sequer foram recuperados, outrossim. Vinga a qualificadora do concurso de pessoas, eis que três foram os assaltantes, e a presença de mais de uma pessoa facilitou a busca da consumação das subtrações. Com uma ação praticou o réu e os demais assaltantes, um acedendo à conduta dos outros, três delitos de roubo, com resultados autônomos, invadindo patrimônios distintos, e de todo cientes de que essa invasão era mesmo de patrimônios diferentes, como bem indicou a prova dos autos sendo as vítimas despojadas individualmente. Caracterizado, assim, o concurso formal de delitos. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, deve a sanção base do delito de roubo qualificado ser aumentada de seis meses, em razão da presença de simulacro de arma de fogo, circunstância judicial desfavorável, aumentando o desvalor da conduta e causando maior temor à vítima, de modo a facilitar a subtração, sendo a pena fixada em quatro anos e seis meses de reclusão e dez dias multa. Na segunda fase de fixação de sanção, devem as penas serem reduzidas ao piso, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com pena de quatro anos de reclusão e dez dias multa. Na terceira fase, aumento as penas de um terço, pela causa de aumento de pena do concurso de pessoas, com sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias multa. Por fim, em razão do concurso

formal de crimes, aumento a pena de um quinto, sendo dois os delitos subsequentes ao primeiro, com sanção final de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e quinze dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu EDVALDO SANTOS GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a cumprir as penas de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa no valor unitário mínimo legal. Iniciará o réu cumprimento de pena em regime fechado, lembrando-se que se trata de crimes de roubo, intrinsecamente graves, sendo os roubos qualificado, em concurso de delitos, e ainda com presença de simulacro de arma de fogo, não se coadunando o delito grave de roubo, nessas circunstâncias concretas, com regime outro que não o mais severo de lei. Não poderá recorrer em liberdade, pelos mesmos motivos. Expeça-se mandado de prisão pela

sentença condenatória ou recomende-se o réu onde se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, conforme o caso. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como o réu, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como o réu. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Diego Melo da Silva, Escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES